

1500124-67.2019.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... juntos. Ele foi preso dois dias depois, por tráfico. Não proferiu ameaças à Daiara. Fugiu enquanto ela atirava, mas ela não viu a direção. Nenhum dos disparos lhe acertou. Estava sozinha quando a discussão se iniciou. Dani chegou durante a discussão. Em nenhum momento tentaram agredir Daiara. Sua sogra não viu seu marido entrando com ninguém na casa. Não havia mais ninguém na rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500124-67.2019.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500124-67.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008504/2019 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 3092407 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 338/19/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2008504 - 03º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIARA DE LIMA MONTEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

DAIARA DE LIMA MONTEIRO, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único (atual § 1º), IV, e artigo 15, ambos da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 08h30min, no cruzamento da Avenida 6 com a Rua M-25, Jardim São Caetano, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria possuído, detido e portado arma de fogo, consistente em um revólver da marca "Taurus", do calibre 38, com a numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, logo

após o delito supra referido, DAIARA DE LIMA MONTEIRO teria disparado a referida arma de fogo em lugar habitado e em suas adjacências.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22) e laudos periciais (fls. 60/61, 88/89 e 97/100).

A ré Daiara foi denunciada como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida (fls. 112/113), a acusada foi citada (fls. 130) e apresentou resposta escrita (fls. 138/139). Foi proferida sentença, sendo desclassificada a imputação quanto ao crime doloso contra a vida, entendendo-se tratar-se na verdade dos delitos previstos nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, tendo os autos sido remetidos e distribuídos à presente Vara Criminal (fls. 220/227)

Posteriormente, foi oferecido aditamento à denúncia nos artigos 16, parágrafo único, IV, e 15, ambos da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, (fls. 268/271), tendo sido recebido (fls. 272).

Superada a instrução penal e a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram alegações finais na forma do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação da ré nos termos da denúncia, requereu o reconhecimento da agravante da reincidência e a prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal, bem como a aplicação do regime inicial fechado. (fls. 325/331)

A Defesa, preliminarmente, requereu a nulidade da nova capitulação jurídica dada aos fatos pelo Ministério Público após a decisão de desclassificação. No mérito, pugnou pela absolvição da ré diante da excludente de ilicitude da legítima defesa, a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório, sendo que no caso de não acolhimento, requereu a absorção do crime de posse de arma de fogo pelo delito de disparo de arma de fogo. Subsidiariamente, apresentou teses relativas à fixação da pena. (fls. 410/421)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar arguida pela Defesa de nulidade da nova capitulação jurídica dada aos fatos pelo Ministério Público após a decisão de desclassificação, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 220/227, que a MM.. Juíza ao proceder à desclassificação da imputação formulada na denúncia, mencionou que entendeu tratar-se, na verdade, dos delitos previstos nos artigos 14 e 15 da Lei 11.826/03, tendo os autos sido remetidos e distribuídos à presente Vara Criminal.

É certo que não se vislumbra óbice na legislação ao Juízo da Vara do Júri quando desclassificar o delito de sua competência (descrito na denúncia) para outro de competência do juiz singular, indicar nova capitulação jurídica, no entanto, tal indicação não é imprescindível.

De outro lado, tem-se que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, de modo que, após a instrução processual, aos fatos poderá ser atribuída definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Além disso, o artigo 127, §1º, da Constituição Federal assegura o princípio da

independência funcional dos integrantes do Ministério Público, de modo a garantir que não se vinculem às manifestações apresentadas anteriormente por outros agentes, gozando de autonomia de convicção, eis que titulares da ação penal pública.

Logo, considerando que a decisão de fls. 220/227, que desclassificou o delito de homicídio doloso tentado para outros de competência do juiz singular detém natureza jurídica interlocutória, a capitulação jurídica dos fatos compete ao juízo singular para onde foi encaminhado o processo, não havendo que se falar, portanto, que em razão do trânsito em julgado da sentença, precluiu o interesse do Ministério Público em ver alterada a capitulação do delito, pois em que pese tenha sido realizada na rr. sentença, repise-se, não era imprescindível.

Corroborando com esse raciocínio, de igual forma já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS Nº 629562 - DF (2020/0315107-8) DECISÃO. [...] Neste writ, a Defesa sustenta a nulidade da nova capitulação jurídica dada aos fatos pelo Ministério Público após a decisão de desclassificação. Nesse sentido, argumenta que o Paciente somente pode ser processado pelo delito "previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal, que foi o único fato reconhecido pelo Tribunal do Júri de Brasília na decisão de desclassificação e aceito pelo próprio Ministério Público, quando não interpôs nenhum recurso contra o acórdão que manteve intacta a decisão de desclassificação" (fl. 9). Assevera que a capitulação jurídica atribuída no momento da desclassificação está acobertada pelo trânsito em julgado, razão pela qual tornou-se inalterável. Alega, ainda, que houve a concordância do membro do Ministério Público atuante no Tribunal de Justiça com a desclassificação, tendo em vista a ausência de interposição de recurso contra o acórdão distrital, motivo pelo qual a alteração da capitulação jurídica pelo Promotor de Justiça em primeira instância ofenderia a unidade e indivisibilidade do Parquet. Pleiteia, liminarmente, a suspensão da ação penal (audiência designada para 30/11/2020) e, no mérito, a declaração da nulidade da denúncia ou a determinação de que ela seja adequada para imputar tão somente o crime previsto no art. 121, § 3.º, do Código Penal. É o relatório inicial. Decido o pedido urgente. Não se constata a plausibilidade do direito alegado, o que impede a concessão da medida liminar pleiteada. Com efeito, é pacífico nesta Corte Superior que "o acusado se defende das condutas que lhe são imputadas e não da capitulação jurídica dada pelo órgão acusatório" (AgRg nos EDcl no REsp 1. 789.343/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020). Em verdade, a classificação jurídica dos fatos pode ser alterada a qualquer momento no curso da ação penal, a pedido do Órgão acusador, ou até mesmo de ofício pelo Magistrado singular, ao proferir a sentença, ainda que a nova definição jurídica dada aos fatos imponha o Réu penas mais graves, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Assim, à primeira vista, revela-se inviável a pretensão de tornar imutável a definição jurídica atribuída aos fatos antes mesmo que eles tenham sido examinados pelo juiz natural da causa. Com efeito, a decisão que desclassifica a conduta após a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri possui natureza jurídica interlocutória, sendo incapaz de formar coisa julgada quanto aos aspectos de mérito da acusação. Desse modo, a classificação jurídica provisória atribuída pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao desclassificar a conduta com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, não vincula a sentença a ser proferida pelo Magistrado que recebeu os autos após a desclassificação, pois este é o juiz natural quanto ao mérito da acusação. De fato, ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri compete apenas verificar se é caso de crime doloso contra a vida ou não, de modo que, constatado que não se trata de delito desta espécie, todas as demais questões meritórias deverão ser submetidas integralmente ao exame do Juízo singular competente, inclusive capitulação jurídica do fato.

(STJ - HC: 629562 DF 2020/0315107-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 30/11/2020)

Assim, deixo de acolher a preliminar arguida pela Defesa, nos termos dos fundamentos ora expostos.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está consubstanciada pela juntada do auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22) e laudos periciais (fls. 60/61, 88/89 e 97/100).

A autoria restou demonstrada a contento.

Ouvida perante a autoridade policial, a ré declarou que na data dos fatos, por volta das 08h30min, Zeneiva Dioclecio foi até a residência da mãe de seu atual marido e os encontrou na cama. Ela já a ameaçava de morte, dizendo que a mataria com uma arma. Em razão disso, comprou um revólver para se defender. Zeneiva a ameaçou novamente, juntamente com outras sete mulheres, sobrinhas e irmãs dela que estavam armadas com pedaços de pau e barras de ferro. Ela pediu que saísse de dentro da casa da mãe de seu atual marido para resolverem a pendência na rua. Disse ter efetuado três disparos com a arma de fogo em direção ao chão, não tendo disparado na direção dela. Sua intenção era assustá-las para que fossem embora do local. Em seguida, foi abordada pela polícia na rua da casa de sua mãe e os policiais localizaram a arma de fogo em sua bolsa. Negou ter atentado contra a vida de Zeneiva. Tem conhecimento de que ela possui uma pistola automática na residência dela, inclusive foi ameaçada com a referida arma no natal. Não soube informar o endereço dela, nem onde a arma pode ser encontrada (fls. 08).

Em juízo, declarou que conheceu o marido de Zeneiva devido a uma dívida de drogas, visto que seu irmão era usuário e o marido dela era envolvido com entorpecentes. Não sabia que ele era casado. Fazia dois meses que residiam juntos em um imóvel que ele alugou, em um condomínio, onde Zeneiva foi ameaçada juntamente com a família dela. Deixou o local devido às ameaças. No Natal estavam separados, mas estava grávida dele e foi ameaçada por Zeneiva e mais 13 pessoas no bairro Cervezão. Na ocasião, apanhou de algumas pessoas, mas não de Zeneiva. Não foi na delegacia. Perdeu o bebê após ter apanhado. Onde Zeneiva a via, ela queria brigar. No dia dos fatos, elas chegaram em sete pessoas, parentes de Zeneiva, munidas com um pedaço de pau e barra de ferro. Estava dormindo e ouviu uma gritaria do lado de fora. Não teve a intenção de matá-la em momento nenhum. Desferiu o primeiro disparo dentro do quarto e elas pensaram que era bomba. Negou tê-la ameaçado e dito que a mataria. Zeneiva não a aceitava, mas ela já a conhecia. Não sabia que ele era casado, pois conhecia apenas os parentes de Zeneiva que moravam no Cervezão e o casal morava no Jardim Progresso. O homem era casado no papel, mas morava consigo em um flat alugado por ele. Seu marido comprou a arma três dias antes dos fatos. Estava residindo com sua mãe. Daniele a conhecia, mas não gostava dela. Foram dois meses de relacionamento, sendo que residiu um mês no flat e frequentava a casa da mãe dele, e no outro mês residiu com sua mãe. No dia dos fatos, dormiu na casa da mãe dele. As sete pessoas chegaram, Zeneiva entrou e as outras permaneceram na rua, gritando para que saísse. Seu marido não queria sair e não queria deixá-la sair. Desferiu um tiro na direção do pé dele, e os outros tiros apontou a arma para cima, na rua. Não havia ninguém perto quando atirou na rua. Foi abordada pela polícia defronte à casa de sua mãe. Acredita que ele estava lá quando a polícia chegou, mas não tem certeza. Ele quem a levou até a residência de sua mãe. Não tinha intenção de acertar ninguém, mas de espantar a todos. (SAJ)

A vítima Zeneiva Dioclecio declarou que todas as manhãs passa na casa de sua sogra, pois ela é doente, além de que tem uma sobrinha, Daniele, que mora com ela e estava grávida na época. No dia dos fatos chegou na residência, entrou e perguntou da Daniele, no que sua sogra respondeu que ela não estava. Viu que a porta do quarto de Daniele estava trancada e perguntou a sua sogra o porquê, então ela respondeu que seu marido havia dormido lá. Havia brigado na noite anterior, motivo pelo qual

ele não dormiu em casa. Como a porta estava trancada, foi até o corredor e avistou, através da janela aberta, seu marido dormindo com Daiara. Não a conhecia. Voltou para a sala e disse à sua sogra que ele estava dormindo com outra mulher. Ela nada respondeu. Ligou para Daniele e sua sobrinha pediu que ficasse calma, pois chegaria logo. Enquanto saiu lá fora para esperá-la, sua sogra foi ao quarto avisá-los de que estava ali. Nesse momento, iniciaram uma discussão, na qual Daiara proferiu que iria matá-la. Falou para Daiara ir lá fora para se resolverem e ela apareceu com uma arma na mão. Quando ela desferiu o primeiro disparo, correu e entrou na casa da vizinha. Na rua, Daiara gritava que a mataria e que ela deveria ir até a M-19 encontrá-la. Acionou a polícia e Daiara foi embora. A polícia demorou um pouco, então foi até a guarnição próxima ao local e chamou a viatura, que conseguiu abordá-la com a arma dentro da bolsa. Não sabe de quem era a arma. Seu marido tentou apaziguar a discussão e saiu para a rua antes de Daiara dar os tiros. Não tinha desconfiança de que ele estava tendo um caso. O motivo da briga no dia anterior não foi esse. Após os fatos, continuaram juntos. Ele foi preso dois dias depois, por tráfico. Não proferiu ameaças à Daiara. Fugiu enquanto ela atirava, mas ela não viu a direção. Nenhum dos disparos lhe acertou. Estava sozinha quando a discussão se iniciou. Dani chegou durante a discussão. Em nenhum momento tentaram agredir Daiara. Sua sogra não viu seu marido entrando com ninguém na casa. Não havia mais ninguém na rua durante a discussão. Quando sua vizinha apareceu, entrou na casa dela. Não encontrou Daiara posteriormente. Seu marido disse que estava com Daiara há um mês e era um relacionamento passageiro. (SAJ)

A testemunha de acusação Rodrigo Aguiar Honda declarou que receberam uma solicitação de disparo de arma de fogo. Dirigiram-se ao local e se depararam com a vítima, que não estava ferida. A vítima disse que o motivo da briga era o relacionamento dela, bem como passou as características da autora dos disparos e o sentido que ela havia tomado. Iniciaram o patrulhamento, visualizaram Daiara, abordaram-na e localizaram a arma no interior de sua bolsa.. Daiara confessou ter efetuado os disparos e disse ter sido pelo relacionamento com o marido da vítima. Não se recorda se Daiara mencionou ter sido agredida, mas ela não tinha lesões aparentes. Não conhecia nenhum dos envolvidos. (SAJ)

A testemunha de acusação, Daniely de Oliveira Chaves, sobrinha da vítima, declarou que na noite dos fatos não dormiu em casa, chegou após o ocorrido. Recebeu uma mensagem de Zeneiva dizendo que ia até sua casa, então foi até lá para encontrá-la. Quando chegou, havia uma discussão entre Zeneiva e Daiara. Daiara estava dentro da residência e Zeneiva estava no quintal. Não entrou em casa. Daiara disse que mataria sua tia. Seu tio estava tentando separar, mas depois ele saiu. Não o viu. Daiara desferiu um tiro, momento em que saiu correndo com sua tia e se esconderam na casa da vizinha. Ouviu três tiros ao todo. Ouviu apenas a discussão e não presenciou Daiara desferindo os tiros. Sua tia chamou a polícia. Não conhece Daiara. Acredita que ninguém sabia que seu tio estava se relacionando com ela. Não viu Zeneiva ameaçando Daiara. Não viu se houve agressão. Não sabe se Daiara dormiu lá na noite anterior. A casa pertence à sua avó, que nada soube informar sobre os fatos. (SAJ)

A testemunha de acusação Valdemir Diogo de Faria declarou que Zeneiva é sua esposa e possuem três filhos juntos, sendo uma de 25 anos, uma de 21 e uma de 16. Estão juntos há aproximadamente 27 anos. Além disso, tem a guarda da filha de sua irmã, que atualmente está com quatro anos de idade. Conheceu Daiara, que foi sua amante. No dia dos fatos, sua esposa os surpreenderam dormindo juntos na casa de sua mãe. Reside com sua esposa, mas havia discutido com ela e dormiu na casa de sua mãe, tendo levado Daiara consigo. Relatou que Zeneiva visita sua mãe com frequência, visto que esta é doente, e quando ela chegou e o viu com Daiara, iniciaram uma discussão. Tentou apaziguar a briga, mas não conseguiu contê-las, então foi embora para a casa de sua tia Aparecida. A discussão ocorreu no corredor da residência. Com relação aos disparos, não presenciou. Não sabia que Daiara estava armada, soube pela sua esposa após os fatos. Não sabe quantos tiros foram disparados, mas

acredita que em torno de dois ou três. Foi a primeira vez que essa situação ocorreu. Não reparou se Zeneiva estava com outras mulheres ou se estava munida com um pedaço de ferro ou um pedaço de madeira. Nunca presenciou ameaças entre elas. Nunca se casou com Daiara, mas estavam juntos. Ela sabia que era casado. Afirmou que além de sua mãe, havia uma vizinha lá, mas não reparou se havia mais pessoas. Zeneiva não tinha arma de fogo e nunca andou armada. Sua mãe nada disse a respeito, mas ficou nervosa. Não era comum que levasse Daiara até a casa de sua mãe, pois geralmente se encontravam na casa da mãe dela. Namorou Daiara por pouco mais de um mês. Sabe que Daiara já teve problemas de briga, mas não tem conhecimento se ela já foi internada em uma clínica. No período que conviveu com ela, não tinha conhecimento de que ela portava arma de fogo. Afirmou que tinha pouco contato com os filhos de Daiara (SAJ).

De rigor a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 16, parágrafo único (atual §1º), inciso IV, e 15, da Lei 10.826/03, tendo em vista que os elementos probatórios de materialidade e autoria angariados nos autos são seguros o suficientes para tanto, senão vejamos

Pois bem. A ré reconheceu tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo que possuía a arma apreendida, tendo informado que havia ganhado de seu marido três dias antes dos fatos. Foi categórica ao afirmar que não detinha a intenção de matar, mas sim de assustar para que fossem embora do local. Afirmou ter efetuado um disparo em direção ao pé dele, e os demais disparou para cima na via pública, momento em que não havia ninguém.

Frisa-se que a confissão da ré acerca da posse da arma de fogo e dos disparos efetuados, confirmada espontaneamente em Juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, bem como aliada aos demais elementos de prova, assumem elevado valor probatório, sobretudo quando a própria ré dá detalhes da ocorrência dos fatos.

Além do mais, corroborando sua confissão, todas as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas ao confirmarem os fatos narrados na exordial, bem como a autoria delitiva de Daiara. Nesse ponto, destaco as declarações prestadas pelo policial militar Rodrigo Aguiar Honda, o qual relatou que naquele dia tomaram conhecimento dos fatos e lograram êxito em abordá-la, ocasião em que localizaram a arma de fogo no interior da bolsa dela. Ela confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo.

Anoto que o depoimento do policial militar merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinha a intenção de incriminar indevidamente a ré, não pesando sobre ele nenhuma suspeição.

Na sequência, tendo em vista que o delito de posse ilegal de arma de fogo é considerado crime de perigo abstrato e de mera conduta, para que o dolo reste configurado basta que haja a infringência de um dos verbos-núcleo do tipo - considerado tipo misto-alternativo -, sendo prescindível a demonstração de perigo concreto, eis que se presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua consecução, de resultado naturalístico à incolumidade corporal de alguém.

Nesse contexto, ressalto que a conduta perpetrada pela ré evidencia potencial lesividade à incolumidade pública e não se revela desproporcional nem ofende a natureza fragmentária do Direito Penal.

Dessa mesma forma tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico

tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social".

(AgRg no REsp nº 1.915.047/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15 de março de 2021, VU).

Destarte, diante da confissão da ré e das declarações uníssonas prestadas pelas demais testemunhas ouvidas em Juízo acerca da materialidade a autoria dos fatos, imperioso se faz, portanto, sua condenação pelo delito previsto no artigo 16, parágrafo único (atual §1º), inciso IV, da Lei 10.826/03.

Quanto ao delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03, também de rigor a condenação da ré.

Como se vê, restou devidamente delineado nos autos que a ré efetuou disparo de arma de fogo em local habitado, sendo evidente a lesão ao bem jurídico protegido, ainda que os projéteis não tenham atingido ninguém.

Em que pese os disparos de arma de fogo tenham sido efetuados para cima, fato é que ainda há exposição de risco direta a todos os indivíduos nas proximidades do atirador, eis que se tratava de via pública.

Da análise dos elementos probatórios angariados nos autos, entendo que não seja caso de aplicação do princípio da consunção. É certo que a absorção do delito de posse de arma pelo de disparo não é automática, uma vez que depende do contexto fático do caso concreto em que se deram as condutas, além do nexo de causalidade, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não se vislumbra.

No presente caso, tem-se que a consumação dos delitos se deram em contextos fáticos diferentes. Conforme a própria ré declarou em seu interrogatório, detinha a posse da arma de fogo há três dias antes dos fatos ocorrerem, tendo o crime de disparo de arma de fogo se dado em virtude de uma situação superveniente à tal aquisição.

Para confirmar a ausência de nexo entre as condutas, basta um simples raciocínio, caso a testemunha Zeneiva não tivesse aparecido no local, e os fatos não tivessem se sucedido, ainda sim a ré deteria a posse da arma de fogo, não havendo que se falar, portanto, que a posse de arma de fogo foi um crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, eis que, em razão de ser um crime de perigo abstrato, sua conduta consumou-se a partir da aquisição do artefato, não havendo que se falar em estrita relação com a conduta subsequente, do contrário, o que se vê são delitos praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos.

Com esse mesmo raciocínio, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 544206 MS 2019/0333574-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Finalmente, deixo de reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa. Fato é que a existência de um conflito por motivos amorosos entre a ré, Valdemir e Zeneiva não justificam o disparo de arma de fogo realizado pela ré, eis que foi muito clara em seu interrogatório ao delinear que visava apenas afugentar Zeneiva e seus familiares.

Tendo isso em vista, torna-se inviável falar em legítima defesa na conduta de disparar arma de fogo, ainda mais quando inexitem nos autos qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de uma injusta agressão sofrida a ponto de permitir que a ré lançasse mão, na ocasião, de uma arma de fogo - frisa-se que em tais casos deve ser observada a necessidade de utilização moderada dos meios necessários, o que não se vislumbra nos autos - sendo que acolher tal alegação equivale a permitir que, em qualquer briga ou conflito amoroso, um dos agentes lance mão de tal artefato como se fosse algo comum, tudo sob a justificativa de "legítima defesa".

Assim, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização do réu pelos delitos previstos no artigo 16, parágrafo único (atual §1º), inciso IV, da Lei 10.826/03, e pelo artigo 15 da Lei 10.826/03, é medida de rigor.

Caracterizados os delitos, passo à fixação das penas, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base da ré no mínimo legal, eis que ausentes circunstâncias judiciais hábeis a majorá-las. Para o delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, sua pena será de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, enquanto para o crime previsto no artigo 16, parágrafo único (atual §1º), inciso IV, da Lei nº 10.826/03, sua pena será de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência (fls. 275 - processo nº 0002488-35.2012.8.26.0283; 0002001-77.2018.8.26.0502 e fls. 277 - processo nº 3003897-56.2013.8.26.0510). Como são três os processos que geraram a reincidência, compenso a atenuante com um dos processos e utilizo a preponderante legal da reincidência, prevista no artigo 67 do Código Penal para aumentar suas penas em 1/6, de modo que passará a 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa para delito de disparo de arma de fogo, enquanto para o delito de posse de arma de fogo será de 03 anos e 06 meses e 11 dias-multa. Anoto que não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada.

Aplicada a regra do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, chega-se ao montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e 22 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, diante da ausência de elementos acerca da situação financeira da ré.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que a acusada é multirreincidente.

A ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, em razão do montante de pena aplicada, que não autoriza a concessão do benefício, bem como diante do fato da ré ser multirreincidente. Pelos mesmos motivos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DAIARA DE LIMA MONTEIRO para CONDENÁ-LA às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 16, parágrafo único (atual § 1º), IV, e artigo 15, ambos da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade acima aplicada pelas restritivas de direito e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da fundamentação.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Determino a remessa da arma apreendida para os fins de direito (Lei 10.826/2003, art. 25, com a redação da Lei 11.706/08), caso ainda não tenha sido feita.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 18 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA